

1514677-92.2019.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FABIOLA OLIVEIRA SILVA

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 16ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/06/2022

... pelo Tribunal Pleno do Colendo STF, "... o tráfico de entorpecentes privilegiado não se harmoniza com a hediondez do tráfico de entorpecentes definido no caput e § 1º do art. 33 da Lei de Tóxicos. O tratamento penal dirigido ao delito cometido sob o manto do privilégio apresenta contornos mais benignos, menos gravosos, notadamente porque são relevados o envolvimento ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

16ª Vara Criminal

Av. Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, Rua 04 1º Piso Salas 1-220 e 1-221, Barra Funda -

CEP 01133-020, Fone: (11) 2868-7091, São Paulo-SP - E-mail: Sp16cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1514677-92.2019.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1514677-92.2019.8.26.0228

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RAFAEL GALORO DE AZEVEDO

Vistos.

RAFAEL GALORO DE AZEVEDO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput" da Lei nº 11.343/06, c/c artigo 29, caput, do Código Penal. porque no dia 17 de junho de 2019, por volta das 18h20, na Rua A, altura do numeral 84, Sacomã, nesta cidade e comarca da Capital, o acusado, previamente ajustado e com unidade de desígnios com terceiro ainda não identificado, guardava, para fins de entrega ao consumo de terceiros, drogas, consistentes em 3,4g (três gramas e quatro decigramas) de cocaína, acondicionados em 6 invólucros, bem como 1,7g (um grama e sete decigramas) de maconha (Skunk) - tudo conforme auto de exibição e apreensão a fls. 16 e laudo de constatação a fls. 30/32 -, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A denúncia foi recebida (fls. 81/82), o réu foi citado (fls. 99) e apresentou resposta à acusação (fl. 104). Mantida a decisão que recebeu a denúncia (fls. 118). Durante a instrução foram ouvidas duas testemunhas e o réu, interrogado ao final. Nos debates, o Ministério Público manifestou-se pela condenação, nos termos da denúncia e a d. Defesa, e declaração da perda do dinheiro. Pela defesa foi requerido o reconhecimento da atipicidade da conduta aplicando-se o princípio insignificância. Subsidiariamente, pugnou a absolvição por falta de provas e o reconhecimento favorável em sede de aplicação de pena.

É o relatório

Fundamento e decido.

A ação penal é parcialmente procedente.

A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 10), boletim de ocorrência (fls. 16/19), auto de exibição e apreensão (fl. 20), laudo de constatação (fls. 34/36), laudo definitivo (fls. 73/75), bem como pela prova oral.

A autoria, de igual modo, restou demonstrada.

Ricardo de Castro, policial civil, relatou que a região é conhecida pela venda de drogas. Já conheciam por conta de prisões anteriores a forma de operação da atividade de tráfico ali. Estacionaram em viatura descaracterizada a distância de cerca de 40 metros e permaneceram em campana. Observaram alguns indivíduos indo até o acusado, ele recebia algo, dirigia-se até um cone, forma de operação conhecida ante a realização de outras prisões no local, retirava as drogas, devolviam o cone ao lugar, e entregavam a droga ao comprador. Abordaram ao acusado após observarem a dinâmica. Como estavam em apenas dois policiais, não puderam perseguir o comprador. O acusado, na ocasião, assumiu a prática dos fatos, disse que ganhava cerca de cem reais por dia, que era seu primeiro dia. O dinheiro foi encontrado com o acusado e era trocado, notas miúdas. Observação a ação de ir até o cone de 4 a 5 vezes.

Marcus Vinicius Ferreira da Silva, policial civil, relatou que houve denúncia de que o local, já conhecido por venda de drogas, continuava a acontecer tais vendas. Estacionaram em viatura descaracterizada e observaram a ação de venda consistente no recebimento de algo, caminhar até o cone e retirar alguma coisa, entregando-a ao comprador. Assim, fizeram a abordagem e encontraram as drogas descritas na denúncia, sob o cone. O próprio réu informou que sempre tem prisões ali, as drogas são abastecidas em pouca quantidade. Suspeitaram de um rapaz que fosse olheiro, mas não conseguiram prendê-lo.

Rafael confessou a prática dos fatos. Trabalhava na feira e foi convidado para praticar a venda das drogas, mediante o pagamento de cem reais, o que seria suficiente para restabelecer a banca na feira. Foi avisado que teria operação na favela, ainda assim arriscou. Confirma as declarações feitas pelos policiais, exceto quanto à declaração de havia olheiro e estavam 5 pessoas ao seu lado.

Apesar da sustentação feita pela combativa defesa, nos autos existem elementos suficientes para a condenação do réu.

Não há nulidade por eventual confissão informal feita aos policiais no momento da abordagem. Não foi empregada isoladamente para compor o arcabouço fático-probatório que embasa a certeza da autoria e prova da materialidade do delito em tela. Ao contrário, a confissão atacada é mero indício, que foi confirmado pelo restante das provas colhidas durante a instrução sob as garantias do contraditório e da ampla defesa. Tal entendimento, encontra-se em plena consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, como verifica-se no trecho a seguir colacionado: “À míngua de alegação ou evidência de que a confissão do local de armazenamento da droga foi obtida mediante coação ou qualquer meio ilícito, também não há como se vislumbrar ilegalidade na confissão informal feita pelo Paciente aos Policiais Militares, indicando a localização da droga em terreno baldio, longe de sua residência” (HC 608.558/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020). Ademais, na fase policial onde colhidos os interrogatórios, constam as advertências.

Por conseguinte, também não se fala em nulidade das provas derivadas do flagrante, dentre as quais figuram os depoimentos dos policiais militares ouvidos em juízo. Isto porque há plena independência entre a confissão informal realizada, a qual não

foi considerada como elemento probatório, e as demais provas colhidas. Desta maneira decidiu o Supremo Tribunal Federal em acórdão no qual reconheceu a nulidade de confissão informal empregada como prova única para a condenação, sem que esta nulidade fosse estendida aos depoimentos dos policiais ouvidos. (RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS 170.843/SP, Rel. MIN. GILMAR MENDES, julgado em 13/06/2019, DJe 14/06/2019).

Não se fala em aplicação do princípio da insignificância. Embora tenham sido apreendidas poucas porções, restou provada a venda, inclusive presenciada pelos policiais e esclarecido que ante as repetidas prisões praticadas ali, os traficantes optaram por abastecer um maior número de vezes ao invés de perderem grande volume de mercadoria em apreensões;

Embora a quantidade seja medida em gramas, não significa que a potencialidade da droga e, portanto, do dano, sejam baixos. Ainda, não se pode considerar insignificante ou irrisória a quantidade descrita na denúncia, nem mesmo sob o ponto de vista do valor econômico que representa. Importante consignar que a lei estabelece uma gradação da resposta penal aos primários, de bons antecedentes, que não se dediquem às atividades criminosas nem integrem organização criminosa. Nestes casos, está prevista a aplicação do redutor do artigo 33, parágrafo 4º, da Lei nº 11/343/2006. Ademais, a venda de drogas como se tem desenhado nestes tempos é feita ao consumidor final, de forma que o vendedor não porta grande quantidade de drogas. Adotar-se a aplicação irrestrita do princípio da insignificância significaria punir-se apenas aos escalões superiores do tráfico, como se os vendedores não estivessem na cadeia do comércio. Esta não foi a escolha legislativa. Por fim, não se pode perder de vista o objeto jurídico tutelado: segurança pública e paz social.

No mérito, há elementos de prova que autorizam a condenação, certo que, nesse contexto probante, inviável o pedido de absolvição, até mesmo porque as provas colhidas fundamentam o decreto condenatório.

A par da confissão exarada tanto na fase policial (fl. 14) como judicial, corroborada pelos depoimentos policiais os quais bem relataram a diligência, inclusive o motivo de verificarem o local, a prática da campana e a abordagem ao réu, corroborados ainda pela apreensão e laudos existentes nos autos. Os depoimentos dos policiais em audiência guardam perfeita consonância com a versão apresentada na fase policial. A par disto, houve apreensão de dinheiro e drogas. Os depoimentos dos policiais que participaram das diligências fornecem embasamento suficiente para respaldar o pedido de condenação do acusado, tendo em vista a coerência e segurança com que foram prestados já que pequenas divergências, que não dizem respeito ao cerne da causa, são naturais dado o curso do tempo e o trabalho diário das testemunhas, que atendem inúmeras ocorrências semelhantes.

Não se deve desconsiderar o teor do depoimento dos milicianos apenas pela sua condição funcional. Nesse sentido: “Os policiais não estão impedidos de depor. Seus depoimentos têm o mesmo valor que outro qualquer. Há dispositivos expressos no Código de Processo Penal determinando que a polícia deverá colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias (art. 6º, III) e que toda pessoa poderá ser testemunha (art. 202). O fato de ter sido a prova acusatória baseada em depoimentos prestados por policiais que procederam à prisão em flagrante não autoriza a absolvição” (TJSP – AC – Rel. Carlos Bueno – RT 654/278) e “Os depoimentos policiais devem ser cridos até prova em contrário. Não teria sentido o estado credenciar agentes para exercer serviço público de repressão ao crime e garantir a segurança da sociedade e ao depois, negar-lhe crédito quando fosse dar conta de suas tarefas no exercício de suas funções precípuas” (TJRJ – AC – Rel. Synésio de Aquino – RDTJRJ 7/287).

Ademais, os policiais não conheciam o réu anteriormente e nada há nos autos que faça presumir que tencionassem prejudicá-lo, imputando a ele falsamente a prática

do delito.

As circunstâncias em que a droga foi apreendida demonstram claramente a sua destinação, não apenas pela variedade, forma de acondicionamento, divididas em pequenas e diversas unidades prontas para entrega a consumidores, além da apreensão de dinheiro, além da constatação de gestual de traficância.

Todos os elementos de prova, portanto, indicam a efetiva responsabilidade penal do agente pelos fatos a ele imputados, não devendo prosperar a negativa.

Em juízo, contudo, nada se comprovou a respeito da participação de terceiro, pois não foi relatado qualquer ato concreto do mencionado "olheiro", senão que correu.

Passo à fixação da pena:

O réu é primário e não ostenta antecedentes que desabonam sua conduta, por tal motivo a pena-base é fixada no mínimo legal, ou seja, 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Em segunda fase, não há agravantes. Embora o réu tenha confessado a prática dos fatos, confissão que fica reconhecida, tendo em conta que a pena já está aplicada no mínimo e a Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, a confissão não ganha efeitos práticos nos autos.

Em terceira fase, aplico a causa de diminuição prevista no parágrafo 4º do artigo 33, da Lei 11.343/06, considerada a primariedade do acusado, além da quantidade de drogas, e diminuo a reprimenda em dois terços, perfazendo 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, tornando-a definitiva nesse patamar à míngua de quaisquer outras circunstâncias a serem consideradas. Ressalto que apenas a quantidade de droga apreendida é insuficiente a demonstrar o efetivo envolvimento do acusado em atividade criminosa.

Como assentado pelo Tribunal Pleno do Colendo STF, "... o tráfico de entorpecentes privilegiado não se harmoniza com a hediondez do tráfico de entorpecentes definido no caput e § 1º do art. 33 da Lei de Tóxicos. O tratamento penal dirigido ao delito cometido sob o manto do privilégio apresenta contornos mais benignos, menos gravosos, notadamente porque são relevados o envolvimento ocasional do agente com o delito, a não reincidência, a ausência de maus antecedentes e a inexistência de vínculo com organização criminosa ..." (STF, HC 118.533/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 23/06/2016).

Desse modo, reconhecido o privilégio, diante da quantidade da pena aplicada, cabível a concessão dos benefícios previstos no artigo 44 e seguintes do Código Penal, com a substituição da pena privativa de liberdade ora imposta por uma pena restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade, bem como por uma pena de multa, calculada no mínimo legal.

Em caso de descumprimento da pena substitutiva e conversão em pena privativa de liberdade, o regime inicial para cumprimento da pena será o aberto, nos termos do artigo 33, parágrafo 2º, alínea "c", do Código Penal.

Dispositivo.

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal e CONDENO o réu RAFAEL GALORO DE AZEVEDO, qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, sendo calculada a pena pecuniária na forma prevista e no valor mínimo fixado pelo artigo 43 da Lei 11.343/06, por não existir razões nos autos para sua exacerbação, sendo substituída a pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade e pena de multa, na forma anteriormente determinada, sendo ainda calculada a pena pecuniária na forma prevista e no valor mínimo fixados pelo artigo 43 da Lei nº 11.343/2006, por não existir razões informadas nos autos para sua exacerbação

Aplicada a substituição, poderá o réu recorrer em liberdade.

Oficie-se visando à incineração da substância entorpecente.

Tendo em vista que o dinheiro apreendido está nitidamente atrelado ao tráfico de entorpecentes, não tendo até o sido demonstrada a origem lícita, em razão da sentença condenatória ora proferida, determino o perdimento nos termos da lei. Oportunamente, oficie-se para transferência do valor e, encaminhamento do bem (fls. 34/35), nos termos do COMUNICADO CG Nº. 805/2019 da E. Corregedoria Geral da Justiça, oficie-se para comunicação sobre o perdimento, encaminhando-se o ofício para a Esplanada dos Ministérios, Bloco T – Ministério da Justiça e Segurança Pública, Edifício Sede, sala 208, Brasília, Distrito Federal, CEP: 070. Após o trânsito em julgado, o nome do réu deverá ser lançado no rol dos culpados. Custas “ex lege”.

Publicada em audiência, saem os presentes cientes.

São Paulo, 22 de junho de 2022.

Fabíola Oliveira Silva.

Juíza de Direito.

Assina digitalmente.